

제51회 상표법 예시답안

안녕하세요. 상표강사 박상환 변리사입니다.

이번 제51회 상표법 시험은 논점 자체는 많이 꼽히던 중요 논점들이었으나 수험생들이 대체로 꺼려하는 것들이었고, 논점 자체만 동일할 뿐 문제유형이 보통 수험가에서 접하던 문제들과는 차이점이 좀 있어서 수험생분들께서 많이 어려워 하셨을 것이라고 생각합니다.

아래에 제시한 예시답안은 개인적인 기준에서 논점에 따른 배점을 분배하고 답을 일부 낸 것이며, 답이 채워지지 않은 부분은 보통 교재에 많이 나와 있는 일반론이거나 결론이 개인마다 달라 질 수 있는 부분들입니다. 따라서 제가 제시한 답안과 다른 논점을 잡았거나 다른 결론을 내리셨다고 해도 너무 걱정하지 않으셔도 될 것입니다^^

시험 보시느라 모두 고생하셨습니다!! 좋은 결과가 뒤따르길 기원하겠습니다.

<문제 1>

I. 설문(1)

1. 문제의 소재 (1점)

2. 종래거절이유 극복여부

(1) 거절이유 (1.5점)

§6①(1)(3)(7)에 해당하는 거절이유 존재.

(2) §6② 의한 극복가능여부 (4점)

1) 의의 및 취지

2) §6①(7) §6②의해 극복가능 여부

3) 사안의 경우

§6②의해 종래거절이유 극복

3. 새로운 거절이유 (2.5점)

(1) §7①(7) 의의 및 취지

(2) 유사판단

동종성 인정O, coffee bean 식별력 없어 요부X 따라서 비유사

(3) 결론

본 조 문제될 수 있으나 적용X 새로운 거절이유 없음.

4. 설문(1)의 해결 (1점)

II. 설문(2)

1. 서설 (0.5점)

(1) 무효심판의 취지 및 적격

(2) 상표와 서비스표의 관계

2. 유사판단 (1.5점)

동종성 인정, 사용에 의한 식별력 취득 의한 표장유사

3. §7①(9)(10) (1점)

출원시 기준으로 국내에 주지·저명하지 않은바 적용X

4. §7①(12) (2점)

(1) 의의 및 취지

(2) 판단시점

견해대립 있으나 판례는 출원시 기준. 출원시 기준이 타당

(3) 사안의 경우

적용X

5. §7①(11)후단 (3점)**(1) 의의 및 취지****(2) 사안의 경우**

등록여부 결정시 기준. 표장 유사 및 동종성 인정. 따라서 적용O

6. 설문(2)의 해결

§7①(11)후단에 의해 승소

III. 설문(3)**1. 문제의 소재 (1점)****2. 甲이 乙에게 권리행사 가부 (4점)****(1) 침해성립요건****(2) 보호범위내 실시인지 여부**

① coffee bean 식별력 없어 유사판단 요부X ∴ 표장 비유사

② 동종성 인정

(3) 선사용권 인정여부

출원전 출처표시로서 인식도 획득하지 못하였으므로 인정X

(4) §51①(2) 효력제한사유 인정여부

coffee bean은 커피에 대한 보통명칭 또는 기술적명칭에 해당하는바 본 규정에 의해 효력제한O

(5) 권리남용

甲은 형식적으로 등록받았고 무효사유 명백한바 권리남용O

(6) 결론

권리행사 불가

3. 乙이 甲에게 권리행사 가부**(1) 서비스표권의 상표적 사용에 대한 효력 (2점)****(2) 사용에 의한 식별력 획득한 표장 효력 (2점)**

① 금지권의 범위

② 효력제한 여부 (제한설vs무제한설)

(3) 저명상표의 효력 (2점)

저명한 등록상표라도 동일·유사범위에만 금지권의 효력 있음(判例)

(4) 결론

커피전문점과 빵이 동종성이 인정되지 않는바 권리행사 할수 없다고 봄이 타당.

4. 설문(3)의 해결 (1점)

<문제2>

I. 설문(1)

1. 문제의 소재 (1점)

2. 본국관청의 역할과 절차수행 (3점)

국제출원서 접수, 기초출원 또는 기초등록, 국제사무국에 송부, 본국관청통한 출원 등

3. 국제사무국의 역할과 절차수행 (3점)

수수료 납부, 방식심사, 국제등록부에 등재, 국제공보에 공고, 지정국 관청에 통지 등

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 (0.5점)

2. 시기면 (2점)

지정통보~12月 (6月 연장으로 18月 가능) → 적절함

3. 내용면 (3점)

지정상품 유사판단, 류구분 관련 → 적절함

4. 설문(2)의 해결 (0.5점)

시기, 내용 모두 적절

III. 설문(3)

1. 문제의 소재 (0.5점)

2. 일본 기초출원 거절결정 확정시 국제등록에 미치는 효과 (2.5점)

집중공격에 대한 내용 서술

3. 우리나라에서 일반 상표출원으로 전환 (§86의39) (4점)**(1) 요건**

i) 집중공격으로 국제등록 소멸, ii) 국제등록소멸일로부터 3월 이내, iii) 국제등록의 지정상품범위 내, iv) 국제등록의 상표와 동일한 상표 출원

(2) 효과

당해 재출원을 국제등록일에 출원한 것으로 봄. 우선권 수반되어있던 경우 우선권의 혜택도 누릴 수 있음.

<문제3>**I. 설문(1)****1. 출원인 적격 (2점)****2. 기능 (2점)****3. 사용주체 (2점)****4. 사용허락 (2점)****5. 설문(1)의 해결 (2점)**

상기 내용들을 비교해본 결과 지리적표시 증명표장이 더 적절하다고 보임.

II. 설문(2)**1. 침해성립요건 (1점)****2. 보호범위 내 실시인지 여부****(1) 상품 (1점)**

지리적 표시단체표장(증명표장)에서는 동일범위에만 소극적 효력 미침.

상품 치즈로 동일.

(2) 상표유사판단 (7점)

지리적 표시가 지리적표시 개념에 부합되게 사용되는 경우 식별력 있음.

“Meaux”와 “Melun”이 요부로 작용. 유사

(3) 설문(2)의 해결 (1점)

甲의 승소 가능성 있음.

III. 설문(3)

1. 상표개념에 부합하는지 여부 (1점)

2. 표장 자체의 식별력 유무 판단 (3점)

“Meaux”와 “Melun”이 국내수요자에게 지명으로 현저히 알려졌다고 보기 어렵고, Brie가 치즈의 한 종류이긴 하나 국내 수요자들에게 치즈에 대한 성질을 직감시킨다고 보기 어려운바 §6①각호의 식별력은 문제없다고 보임.

3. “평창 Brie de Meaux”에 대하여 (3점)

(1) §7①9의2, 11, 14에 대한 판단

국내 수요자들에게 알려졌다는 사정 없고, 주류가 아닌바 본 규정 적용X

(2) §7①12의2

외국에 알려진 것도 적용 가능. 유럽에 Meaux가 치즈 출처표시로 인식되어 있고, 乙의 부정한 목적 인정하여 적용 가능하다고 봄이 타당.

(3) §7①17

부속서에 포함되어 있는바 적용 가능.

4. “평창 Brie de Melun”에 대하여 (3점)

(1) §7①9의2, 11, 14에 대한 판단

국내 수요자들에게 알려졌다는 사정 없고, 주류가 아닌바 본 규정 적용X

(2) §7①12의2

외국에 알려진 것도 적용 가능. 유럽에 Melun가 치즈 출처표시로 인식되어 있고, 乙의 부정한 목적 인정하여 적용 가능하다고 봄이 타당.

(3) §7①17

부속서에 포함되어 있지 않은바 적용 불가능.

5. 설문(3)의 해결

<문제 4>

I. 설문(1)

1. 거절이유 제1점의 구체적 적용 법규정 - 시각적 표현의 의미 (3점)

(1) §2①(1)다목

(2) §9③

(3) §23①(4)

2. 甲의 유의점 - 시각적 표현 기재방법 (4점)

심시기준 제32조의2, 제75조 등

II. 설문(2)

1. §7①(13)내용 (2점)

2. 기능성 판단방법 (4점)

특성으로 부터 발생하는 특정한 소리, 사용에 꼭 필요하거나 그 상품에 일반적으로 사용되는 소리, 상품의 판매 증가와 밀접한 원인이 되는 소리 (심사기준 제27조)

3. 설문(2)의 해결 (1점)

상기 내용에 따라 기능성 없음을 주장

III. 설문(3)

1. 소리상표의 권리범위 (2점)

2. 유사판단 (2점)

소리상표는 같은 유형의 상표간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단 (심사기준 제21조)

3. 설문(3)의 해결 (2점)

같은 유형이라고 볼 수 없으므로 심사기준에 따라 비유사. (but 유사여지를 완전히 배제할 수는 없다고 보입니다.)